

共犯の成立要件に関する次の【見解】に従って後記アからエまでの各【記述】を検討し、甲及び乙のいずれについても犯罪が成立しない【記述】を選んだ場合、後記1から5までのうち正しいものはどれか。

【見 解】

共同正犯の成立については、違法性阻却事由又は責任阻却事由が一部の共同者に認められても、それは他の共同者には影響しない。

教唆犯・幫助犯の成立については、正犯の行為に構成要件該当性及び違法性が認められることが必要であり、正犯に責任阻却事由が認められても、それは教唆者・幫助者には影響しない。

【記 述】

ア. 甲と乙は、共同して丙に傷害を負わせる意思をもって丙を殴って同人に傷害を負わせた。その際、甲は、正当防衛の要件を充足する状況になかったが、乙は、その要件を充足する状況にあった。

イ. 甲は、乙に対し丙に傷害を負わせるように教唆し、それにより、乙は、丙を殴って同人に傷害を負わせた。乙は、教唆された時には責任能力を欠く状況になかったが、丙を殴った時には責任能力を欠く状況にあった。

ウ. 甲は、乙が丙に傷害を負わせようとしているのを知って乙に角材を渡して幫助した。その後、乙は、前記角材で丙を殴って同人に傷害を負わせたが、その際、乙は、正当防衛の要件を充足する状況にあった。

エ. 甲と乙は、共同して丙に傷害を負わせる意思をもって丙を殴って同人に傷害を負わせた。その際、甲は、責任能力を欠く状況になかったが、乙は、責任能力を欠く状況にあった。

1. ア イ ウ エ
2. ア イ エ
3. イ
4. ウ エ
5. ウ

No147

共犯の従属性

正答率

H21-14

正解

5

94%

ア 甲に犯罪（傷害罪の共同正犯）が成立する

本記述では、正当防衛状況（違法性阻却事由）が一部の共同者である乙にのみ存在するため、他の共同者である甲の罪責が問題となる。この点、「見解」前段に従えば、共同正犯者間で違法性は個別的に作用するため、乙の違法性阻却事由は甲の罪責に影響しない。よって、乙に傷害罪は成立しないが、甲には傷害罪の共同正犯が成立する（60条、204条）。したがって、本記述は、甲及び乙のいずれについても犯罪が成立しない場合とはいえない。

イ 甲に犯罪（傷害罪の教唆犯）が成立する

本記述では、正犯である乙が実行行為時に責任能力を欠くため、教唆者である甲の罪責が問題となる。この点、「見解」後段に従えば、正犯と教唆者との間で責任は個別的に作用する。本記述では、正犯である乙の行為が構成要件該当性及び違法性に欠くところがない以上、乙の実行行為時に責任阻却事由が存在しても、甲の教唆犯成立は妨げられない。なお、「見解」によれば、「教唆犯・幫助犯の成立については、正犯の行為に構成要件該当性及び違法性が認められることが必要」だとされているので、教唆犯の成否に関し問題となる責任能力の有無は、教唆時ではなく、正犯の実行行為時に問題となる。よって、乙に傷害罪は成立しないが、甲には傷害罪の教唆犯が成立する（61条1項、204条）。したがって、本記述は、甲及び乙のいずれについても犯罪が成立しない場合とはいえない。

ウ 甲及び乙のいずれについても犯罪は成立しない

本記述では、正当防衛状況（違法性阻却事由）が正犯である乙に存在するため、幫助者である甲の罪責が問題となる。この点、「見解」後段に従えば、幫助犯の成立には正犯行為に違法性が認められる必要がある。本記述では、違法性阻却事由が乙に存在する以上、甲に幫助犯は成立しない。よって、甲及び乙のいずれについても傷害罪は成立しない。したがって、本記述は、甲及び乙のいずれについても犯罪が成立しない場合といえる。

エ 甲に犯罪（傷害罪の共同正犯）が成立する

本記述では、一部の共同者である乙のみが責任能力を欠く状況にあるため、他の共同者である甲の罪責が問題となる。この点、「見解」前段に従えば、共同正犯者間で責任は個別的に作用するため、乙の責任能力の欠如は甲の犯罪の成否に影響しない。よって、乙に傷害罪は成立しないが、甲には傷害罪の共同正犯が成立する（60条、204条）。したがって、本記述は、甲及び乙のいずれについても犯罪が成立しない場合とはいえない。